

1501181-86.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160641/2021 - 01º D.P.

ITAPECERICA DA SERRA, 18492156 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 719/21/425 - 01º

D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2160641 - 01º D.P. ITAPECERICA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501181-86.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501181-86.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160641/2021 - 01º D.P.

ITAPECERICA DA SERRA, 18492156 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 719/21/425 - 01º

D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2160641 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DOS SANTOS MIRANDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ALEX DOS SANTOS MIRANDA (fls. 71/72), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

No dia 14 de junho de 2021, por volta das 14h20min, na Rua José Acron, 100, Jardim Jacira, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado guardava e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 14 porções de maconha, com peso líquido total de 20,7g, além de 16 invólucros contendo cocaína, totalizando um peso líquido total de 8,2g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 10/11 e laudo de constatação às fls. 12/14.

Regularmente notificado, o denunciado apresentou defesa prévia, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 95/98).

A denúncia foi recebida em 14.07.2021, tendo sido designadas audiências de instrução e julgamento.

Nas datas aprazadas, colheram-se os depoimentos das testemunhas, e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pugnando pela procedência da pretensão punitiva (mídia audiovisual da segunda audiência).

Em memoriais, a defesa pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 138/139).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 7/9), nos autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar das substâncias apreendidas (fls. 10/11 e 12/14) e no laudo definitivo (fls. 90/92). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidos em poder do acusado 14 porções de maconha, com peso líquido total de 20,7g, e 16 invólucros contendo cocaína, totalizando um peso líquido de 8,2g. O exame químico-toxicológico atestou que as substâncias entorpecentes apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, os dois policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, Raonne Rodrigues Ferreira e Rodrigo Aparecido Soares da Silva, apresentaram versões harmônicas, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Ambos relataram que: no dia dos fatos, dirigiram-se ao local dos fatos, ponto conhecido como de tráfico de drogas, a bordo de viatura descaracterizada; procederam à observação velada a distância, ocasião em que viram um indivíduo na via pública; deste se aproximaram três pessoas em sequência, as quais entabularam rápida negociação consigo, entregando-lhe algo e recebendo uma mercadoria em troca, deixando o local em seguida; abordaram o increpado, tendo encontrado, dentro de uma sacola plástica que estava no chão a cerca de três metros dele, as drogas apreendidas, além de R\$ 33,00 em espécie. Indagado, informalmente o imputado admitiu a mercancia ilícita dos estupefacientes (fls. 2 e 3).

Em juízo, inquiridos como testemunhas, os policiais reproduziram, essencialmente, as narrativas extrajudiciais, atestando a veracidade dos fatos imputados na denúncia e elucidando os detalhes da diligência realizada (mídia audiovisual da primeira audiência).

Silente em solo policial (fl. 5), perante este Juízo o acusado negou a prática delitiva, alegando, em suma, que estava no local apenas de passagem para a sua residência quando foi pego pelos policiais, os quais lhe exibiram uma sacola plástica, imputando-lhe a propriedade das drogas que estavam no interior dela (mídia audiovisual da segunda audiência).

A versão apresentada pelo acusado, afora ser fruto do exercício do direito à autodefesa, inclusive de mentir, restou isolada no conjunto probatório, não se afigurando verossímil, muito menos resistindo ao confronto com os demais meios de prova carreados aos autos, convincentes e bastantes para lastrear o édito condenatório.

A par de os depoimentos dos policiais civis serem seguros, claros e congruentes, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra deles tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu – em razão, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Sobretudo em casos como o presente, envolvendo tráfico de drogas, há de se atribuir especial realce aos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, que têm o dever legal de preservar a ordem pública. Não se

patenteou a intenção dos agentes policiais em incriminar gratuitamente o acusado e/ou mero interesse em justificar a abordagem e a prisão, e as versões fáticas não se mostraram facciosas, não subsistindo motivo para desmerecê-las.

Embora o réu meneie a evasiva tese de que as drogas foram “forjadas” pelos policiais, tal argumentação não é minimamente crível. Foi apreendida quantidade razoável de substâncias entorpecentes de natureza diversificada – sendo que um flagrante por tráfico poderia ser “fabricado” com uma quantidade consideravelmente inferior, caso fosse esse o intento dos agentes públicos -, e a origem lícita e as razões para o armazenamento das drogas encontradas em poder do acusado não foram comprovadas nos autos.

Nesse cenário, a defesa não comprovou o fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva alegado (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas. Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Tampouco há de ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado, estampada no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

No que diz especificamente com o requisito negativo da não dedicação a atividades criminosas, CLEBER MASSON pontua que “(...) a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso pode (e deve) ser utilizada pelo magistrado como circunstância apta a afastar a figura privilegiada, pelo fato de indicar a dedicação do agente a atividades criminosas, nada obstante seja vedado utilizar tais fatores como circunstância judicial desfavorável, na dosimetria da pena-base, uma vez que não caracterizam maus antecedentes.” (Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019).

Comungando do mesmo entendimento, RENATO BRASILEIRO DE LIMA ressalva que, “conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para formar a convicção de que o réu se dedique a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Não se trata de avaliação de inquéritos ou processos penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas sim uma forma de se afastar um benefício legal, porquanto existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que, em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma

harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeros processos penais ou seja investigado é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena.” (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.085).

Esse entendimento doutrinário tem ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do EResp 1.431.091/SP em 14.12.2016, pela 3ª Seção, sob a relatoria do eminente Ministro Felix Fischer, ocasião em que se obtemperou que “o crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, LXII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação da proteção deficiente”.

A partir desse precedente, a Corte Superior de Justiça vem majoritariamente reafirmando, por meio de suas duas turmas com competência criminal, o posicionamento no sentido de que a existência de persecuções penais pendentes de definitividade é apta a afastar o redutor em análise quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (no ponto: HC 450.153/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2018; AgRg no AREsp 1.251.694/SP, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 05.08.2018; HC 442.254/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2018; AgRg no AREsp 999.769/RS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06.11.2017; e AgRg no RESp 1.678.417/GO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Ribeiro, j. 17.04.2018).

Essa compreensão também prepondera no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (confirmam-se, por todas: Apelação Criminal nº 1501744-74.2018.8.26.0567, 7ª Câmara, rel. Des. Otavio Rocha, j. 13.06.2021; Apelação Criminal nº 0000118-89.2018.8.26.0019, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 02.06.2021; Apelação Criminal nº 1527069-30.2020.8.26.0228, 2ª Câmara, rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 24.05.2021; Apelação Criminal nº 1510569-83.2020.8.26.0228, 12ª Câmara, rel. Des. Vico Mañas, j. 12.05.2021; e Apelação Criminal nº 1502243-35.2019.8.26.0628, 1ª Câmara, rel. Des. Diniz Fernando, j. 19.04.2021).

Na espécie, consta da certidão de fls. 132/133 que está em trâmite outra persecução penal em desfavor do acusado (autos nº 1502126-73.2021.8.26.0628), deflagrada pouco mais de 5 meses após os fatos que ora se lhe imputam. Apesar de ser tecnicamente primário, o réu já teve outro envolvimento criminal, pela suposta prática do delito do art. 180, caput, do Código Penal, tendo sido preso em flagrante logo após ser beneficiado com a liberdade provisória nestes autos. A reiteração de condutas delituosas em curto espaço de tempo, ainda que não decorra de condenações transitadas em julgado, demonstra a dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e/ou causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo CP (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias estatuídas pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A natureza (cocaína e maconha) e a quantidade não portentosa das drogas não ensejam maior reprovação penal. Noutro giro, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitiva; o réu não ostenta condenações criminais anteriores transitadas em julgado, e a persecução penal em andamento não

pode ser considerada para exasperar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ); o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes, remanescendo a pena inalterada.

Na terceira fase, também não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento, ao que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.700/MG, ratificou o entendimento gizado de forma incidental pelo Plenário, no julgamento do HC 111.840/ES, de que é inconstitucional o art. 2º, §1º, da lei 8.072/1990. Donde a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo - posição que está em consonância com as Súmulas nºs 718 e 719 do STF.

Mais recentemente, sufragando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do HC nº 596.603-SP, publicado em 22.09.2020, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Faustino Neto, condenado como incurso no art. 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedeu ordem individual e coletiva, constando da parte dispositiva:

1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.
2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto.
3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.
4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (Negritei).

A Corte Superior de Justiça estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais de todo o País, dentre as quais:

2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD)

2.c. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução nº 5 do Senado Federal, decorrente do julgamento do HC 97.256,

pelo STF).

Nessa ordem de ideias, fixo o regime semiaberto para início do resgate da pena corporal, em vista do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, mercê da quantidade da sanção corporal imposta (arts. 44, I, e 77, caput, do CP, a contrario sensu).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu ALEX DOS SANTOS MIRANDA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu a este processo em liberdade, foi apenado com sanção privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, cenário incompatível com a prisão preventiva (vide, por todas, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência), de modo que, na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito do acusado de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal), salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera bem jurídico difuso, e não houve pedido expresso da acusação nesse tocante.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do agente em favor da União – consoante fundamentação supra -, o que faço com fulcro no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.343/2006. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários em favor do nobre patrono nomeado no valor máximo previsto na tabela vigente.

Certificado o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado, para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; (d) oficie-se ao IIRGD, para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Cumpridas as demais atribuições cartorárias de praxe, arquivem-se os autos definitivamente, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapeccerica da Serra, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA